



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2012.0000023862

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0056445-78.2006.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO DE SOUZA sendo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto por Roberto de Souza, apenas para reconhecer a continuidade delitiva e reduzir a pena para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, afastado o concurso material do artigo 69 do Código Penal, por infração do artigo 214 c.c. artigo 225, § 1º, inciso II e artigo 226, inciso II, (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal mantida no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente), SILMAR FERNANDES E ANTONIO LUIZ PIRES NETO.

São Paulo, 30 de janeiro de 2012.

PAULO ROSSI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Apelação nº 0056445-78.2006.8.26.0050
Comarca de São Paulo - 9ª Vara Criminal
Apelante: Roberto de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 7290

CRIMES SEXUAIS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRELIMINARES – Ofensa à ampla defesa por não pontuar a data do delito no aditamento à denúncia, e por não especificar em que consistiu a violência empregada contra a vítima - Preliminares afastadas – MÉRITO – Pugna pela absolvição diante da insuficiência probatória - Impossibilidade – Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo se corroborada por todos os outros elementos de convicção contidos nos autos, em contraposição à contraditória negativa do acusado – PENA – Inaplicabilidade do artigo 9º da Lei 8.072/90 – Possibilidade – Revogação tácita pela Lei 12.015/09 – “Novatio legis in melius” Pena reduzida. Recurso parcialmente provido.

Vistos.

1 – Trata-se de Recurso de apelação interposto por Roberto de Souza, contra a r. sentença datada de 24/05/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a cumprir a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 214 c.c. artigo 225, § 1º, inciso II e artigo 226, inciso II, (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, facultado o recurso em liberdade (fls. 157/176).



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Inconformada, a Defesa apresentou razões de apelação, argüindo preliminar de nulidade do aditamento à denúncia, por ofensa ao princípio da ampla defesa, eis que não indicou a data precisa do fato criminoso, reportando-se vagamente a um período “*anterior a 04/06/2006*”; nulidade da denúncia por haver noticiado a prática do delito mediante violência real e ficta sem, contudo, descrever em que consistiu a referida violência real.

No mérito, pugna pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Penal, diante do frágil conjunto probatório. Aduz que o réu sempre negou a autoria dos fatos, e a condenação se lastreou exclusivamente nos depoimentos da vítima e de sua mãe. Afirma que não raro, a mulher imputa a prática de atos daquela natureza ao marido por vingança, contra os próprios filhos do casal, haja vista que no caso dos autos, ela era frequentemente agredida pelo réu, o que traduz a chamada “*alienação parental*”. Por outro lado, se a testemunha declarou ter flagrado o réu imediatamente após a prática do ato, quando limpava suas mãos e as da vítima na roupa, incumbia à acusação o pedido de exame pericial naquelas peças para atestar a presença de esperma, na busca da verdade real. Assevera que nos crimes que deixam vestígios, o exame pericial de corpo de delito é indispensável, por expressa disposição legal (artigo 158 do CP).

Subsidiariamente, requer a absolvição pelo atentado violento ao pudor supostamente ocorrido antes de 04/06/2006, por absoluta falta de provas; o afastamento da causa de aumento descrita no artigo 9º da Lei 8.072/90, por inconstitucional



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

nos casos de estupro ou atentado violento ao pudor com violência presumida, que não integra o rol dos crimes hediondos, além do que, tratando-se de norma penal em branco que depende do art. 224 do CP para ser interpretado, com a revogação deste pela Lei 12.015/09, também está revogado aquele dispositivo, de forma indireta; e o reconhecimento da continuidade delitiva (fls. 194/209).

O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou pelo afastamento das preliminares argüidas e o improvimento do recurso, reiterando os termos de suas alegações finais de fls. 153/154 (fls. 211/213).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial ao recurso para, rejeitadas as preliminares, afastar a incidência do artigo 9º da Lei 8.072/90, reconhecer a continuidade delitiva e reduzir a pena para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob o regime fechado (fls. 219/222).

Este, em síntese, é o relatório.

2 – A preliminar argüida pela defesa, quanto a deficiência da denúncia, não merece acolhimento.

Em que pese vaga a data do fato na inicial acusatória, não se logrou demonstrar qual o prejuízo advindo ao apelante.

Os fatos estão devidamente narrados, sendo que a mera omissão quanto à data pontual de sua ocorrência não determina a rejeição. Tanto é assim que foi regularmente recebida para dar início à ação penal e, em aditamento, nada



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

postulou a Defesa antes do recebimento pelo Juízo.

Conforme se observa dos autos, a referida peça contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e o rol de testemunhas, presentes, portanto, todos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a jurisprudência amplamente majoritária se posiciona no sentido de que:

"A falta de menção à data dos fatos, embora a designação cronológica seja mesmo de rigor, não é bastante para anular a peça acusatória, impondo-se relegar rigorismos formais se for possível aferir a inexistência de concretos prejuízos para o exercício da ampla defesa ou para a apuração da verdade real, nos termos do art. 563 do CPP" (RT 779/675).

Cumprе consignar que a denúncia da promotoria pública não omitiu a data do fato delituoso, apenas mencionou o período a que teria ocorrido, por falta de elementos que possibilitasse a definição pontual do dia, nada mais. Esse defeito, não argüido no momento processual oportuno, não provocou nenhum prejuízo ao réu.

Já se decidiu, ademais, que a omissão de referência a dia e hora da prática do crime não torna inepta a denúncia, desde que suprível com os elementos dos autos (RT 440/372 e 660/283). E ainda: a omissão quanto à data do crime, por si só, não invalida a denúncia, uma vez que a eventual nulidade depende de prova de cerceamento ou embaraço da defesa (RT 423/368).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Nesse sentido:

"I- Se na denúncia houve a devida exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias, com supedâneo nos elementos colhidos na fase inquisitorial, resultando na classificação do delito imputado ao paciente, é irrelevante a ausência de indicação da data da última ocorrência dos atos libidinosos, eis que não prejudica a defesa do paciente. II - Eventual inépcia da exordial acusatória só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP - o que não se vislumbra, in casu" (STJ - 5ª T. - RHC 11.839 - Rel. Gilson Dipp - j. 19.02.2002 - JM 160/621).

"A omissão da data do cometimento do delito, como também do lugar em que o mesmo ocorreu, não invalida a denúncia, pois tais requisitos são meramente acidentais" (TJMG - AP - Rel. Reis Alves - RT 422/377 - apud Franco, Alberto Silva et alii, CPP e sua interpretação jurisprudencial, 2ª ed., vol. 2, São Paulo: RT, p. 368).

Eventual deficiência da denúncia, com efeito, pode ser suprida a qualquer tempo, antes da sentença final de primeiro grau (artigo 569 do Código Penal). Contudo, em alguma situações, trata-se de defeito mínimo que sequer exige o aditamento, conforme orientação jurisprudencial citada nas contra-razões do Ministério Público (fls. 212/213).

Ademais, a referida arguição é



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

extemporânea, porque já prolatada a sentença (art. 569 do CPP), na esteira de entendimento jurisprudencial erigido à espécie, a saber:

"Denúncia, Inépcia. Arguição até a prolação da sentença. Necessidade. Reconhecimento posterior. Impossibilidade: a inépcia da denúncia deve ser argüida antes da prolação da sentença, sendo inviável o decreto de nulidade da inicial, a teor do art, 569 do CPP, pois opera-se a preclusão quando a defesa resta inerte nas oportunidades que se lhe ofereceram " (Ap. nº 1003.595 - j . 26/02/96 - Rel. Wilson Barreira – 11ª Câmara).

A segunda preliminar de nulidade suscitada pela defesa, com relação a alegada violência real mencionada mas não individualizada no aditamento à denúncia, também deve ser rejeitada.

Com efeito, o aditamento apenas fez acrescentar a prática delituosa pelo réu em período anterior ao inicialmente noticiado, mantendo a descrição fática inicial. Dessa forma, pouco importa se houve menção à violência real praticada, pois a Lei já presume a violência em razão da idade da vítima, e em nada altera a tipificação da conduta.

Ademais, a Defesa não se manifestou a respeito no momento oportuno, sendo o aditamento recebido e julgado o processo.

Não bastasse isso, em 10.8.2009, entrou em vigor a Lei nº 12.015, de 7.8.2009, que revogou esse artigo, mas continuou a prever a conduta de atentado violento ao pudor como



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

crime, só que agora, junto com a conduta configuradora do delito de estupro, no art. 213, com algumas qualificadoras antes inexistentes.

Com o advento da Lei nº 12.15/09, o legislador criou a figura do estupro vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), o qual abarca a hipótese em que a vítima possui menos de quatorze anos de idade, *in verbis*:

Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Assim, considerou a impossibilidade de resistência da vítima por já se encontrar em situação de vulnerabilidade que a impeça, de forma absoluta, resistir ao estupro, tornando dispensável o emprego de violência ou grave ameaça pelo agente para a consumação do delito.

A propósito:

“Desnecessidade de violência real ou presumida no crime de estupro de vulnerável – STJ: (...) A configuração do tipo estupro de vulnerável prescinde da elementar violência de fato ou presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos, como se vê da redação do art. 217-A, nos termos da Lei 12.015/2009” (EDcl no AgRg no Ag 706012-GO, j. 23-2-2010, DJe 22-3-2010).

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Consta da denúncia que no dia 04/06/2006, pelas 21h30, na Rua Cruz do Espírito Santo, 605, Bloco 03, AP. 323, em Guaianazes, nesta Capital, Roberto de Souza constrangeu Andressa Pereira de Souza, com 07 anos de idade, mediante violência, a permitir que com ele praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Segundo o apurado, o acusado era companheiro da mãe da vítima e moravam todos sob o mesmo teto. No dia dos fatos, ao verificar que o acusado estava deitado com sua filha, sua companheira entrou no quarto e flagrou Roberto esfregando o pênis já ereto no corpo da menor, forçando-a a masturbá-lo.

Houve representação criminal e a demonstração do estado de pobreza (fls. 1D/2D).

A denúncia foi oferecida em 09/04/2007 (fls. 47) e aditada em 17/05/2007, para constar que o réu é pai da vítima Andressa, tornando-o incurso no artigo 214, c.c. 225, § 1º, II e 226, II e III, todos do Código Penal (fls. 51), e recebida a denúncia e o aditamento em 13/07/2007 (fls. 55).

O apelante foi citado por edital (fls. 68/69) e pessoalmente (fls. 107/108), e interrogado (fls. 150/151).

Em face das declarações da vítima em Juízo, a denúncia foi novamente aditada em audiência, aos 13/05/2010, para que nela constasse que o acusado, em data anterior a 04/06/2006, no período noturno, na Rua Cruz do Espírito Santo, 605, bloco 03, ap. 323, em Guaianazes, nesta Capital, pelo menos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

por duas vezes constrangeu a vítima Andressa Pereira de Souza, com sete anos de idade, mediante violência real e ficta, a permitir que com ele praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ou seja, que o réu lhe esfregasse o pênis, além de forçá-la a masturbá-lo, respondendo pelo crime em concurso material (fls. 152).

Dada a palavra à Defesa, nada requereu e o aditamento foi recebido (fls. 153).

A r. sentença foi publicada em 24/05/2010 (fls. 177).

Em juízo, o apelante negou a imputação. Disse acreditar que a acusação resulta de vingança da mãe da vítima, pois ela não queria mais que dormissem juntos e dizia que sonhava em ficar sozinha. Assim, *“fez a cabeça”* da sua filha, jamais praticou ou tentou praticar qualquer ato libidinoso com a menor. Na data dos fatos, seus filhos estavam deitados com o depoente na cama e a mãe da vítima podia ver o que estava acontecendo, pois a porta estava aberta impossibilitando a prática imputada. A vítima insiste em acusar o depoente da prática de crime, talvez por influência da mãe. Nunca agrediu sua companheira, apenas uma vez que ela o agrediu com uma jarra na cabeça, e o depoente revidou, atingindo-a levemente no nariz. Não sabe indicar outro motivo pra estar sendo incriminado falsamente por elas. Acredita que a mãe da vítima seja desequilibrada, pois tinha alterações de humor. O depoente era quem sustentava a casa à época dos fatos, atualmente mantém breve contato com os filhos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

nas visitas que faz. Indagada pelo depoente sobre a razão de o estar acusando dessa forma, a vítima respondeu estar sendo obrigada pela mãe (fls. 150/151).

A vítima Andressa Pereira de Souza, em juízo, declarou que tem 11 anos de idade. Na época dos fatos, juntamente com seu irmão, costumavam deitar na cama com seu pai, depois que ele chegava do trabalho para conversar. Em determinado dia, ele mandou que a depoente colocasse a mão no seu pênis, e fez isso algumas vezes, até que, naquele dia, sua mãe foi chamá-la para jantar e flagrou o ocorrido. Isso já vinha acontecendo anteriormente, mas a depoente não sabe precisar quantas vezes. Ele nunca tentou estuprá-la, apenas queria que mexesse no seu pênis (indagada a respeito, a vítima não demonstra saber o que é ejaculação ou masturbação, mesmo em termos coloquiais). Ele também a mandava baixar as calças, mas não se lembra se colocava o dedo em sua vagina. Afirma que tinha sete anos e não contava para sua mãe a pedido do réu. Já não se lembra se ele dizia que bateria ou ameaçava de deixar de dar algum presente. No dia seguinte aos fatos, sua mãe conversou com vizinhos, e quando o réu voltou para casa depois do trabalho, foi agredido por eles e saiu de casa. Chegou a ver seu pai bater em sua mãe antes dos fatos, uma vez. Depois, passou por tratamento psicológico na “rede criança”, mas parou por falta de dinheiro. Atualmente é atendida em um posto de saúde. Seu pai a vê quinzenalmente, sempre mediante supervisão da mãe. Fica consignado que a vítima apresenta relato firme e demonstra



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

tranquilidade, embora aparente bastante introversão (fls. 144/145).

A testemunha Carmita Gonçalves Pereira, mãe da vítima, declarou que viveu com o acusado por mais de 10 anos e desse relacionamento tiveram dois filhos, a vítima Andressa e um menino atualmente com 13 anos de idade. No dia dos fatos, abriu a porta do quarto do casal e se deparou com o réu deitado na cama com a vítima, dizendo-lhe para passar a mão em seu pênis. Ao ser surpreendido, ele se levantou dizendo que não era aquilo que a depoente pensava, enquanto tentava levantar as calças para cobrir sua genitália. Ao mesmo tempo, limpava as mãos na roupa, pois havia ejaculado. A vítima também se levantou, tentando se vestir. A calça do pijama dela estava abaixada. Ela também limpava as mãos na roupa. No mesmo dia, conversou com Andressa, na época com sete anos de idade. Chorando, ela disse que há muito tempo o réu vinha tendo essa atitude, mandando que pegasse no seu pênis e o masturbasse. Além disso, ele colocava o dedo em sua vagina. Ela também contou que o pai lhe dissera que, quando fosse mais velha, ele colocaria o pênis em sua vagina. Eles não tiveram conjunção carnal. Segundo a vítima, ele lhe pedia para não contar nada e sempre agia no quarto do casal. A depoente afirmou que já fazia algum tempo que via o réu chamando a vítima para o quarto e lá permaneciam de portas fechadas, mas nunca desconfiou de nada, pensou que pudessem estar conversando sobre a escola ou coisas semelhantes. O réu sempre foi violento com a depoente e a agredia fisicamente na frente das crianças, razão pela qual não tomou qualquer atitude na hora. No dia seguinte, a depoente se aconselhou



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

com vizinhos e compareceu à delegacia de polícia para noticiar os fatos. Na mesma semana, expulsou o acusado de casa. Depois que tiveram o segundo filho, a depoente parou de trabalhar, pois seu filho tem problemas psiquiátricos, mas não acredita que o réu abusasse dele. O réu paga pensão para sustento das crianças. Nunca mais permitiu que ele ficasse sozinho com os filhos nas visitas, somente mediante supervisão, e nunca dentro da casa. Após os fatos, a vítima fez acompanhamento psicológico por quatro anos, na “rede criança”, e hoje é atendida por psicólogos do posto de saúde. Até hoje, ela é muito nervosa. Desde então, não teve mais contato com o réu e desconhece qualquer fato de sua vida (fls. 146/147).

As testemunhas Marinalva Chagas de Oliveira Gimenes e Ricardo Lima de Souza nada acrescentaram, apenas disseram ser sobrinhos da primeira mulher do réu e do réu, respectivamente, e não freqüentavam sua casa (fls. 148/149).

Diante de todo o quadro probatório, dos depoimentos das testemunhas e, principalmente, da palavra da vítima, verifica-se que a condenação era mesmo de rigor.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), laudo pericial de sexologia forense (fls. 10), termo de representação (fls. 13), ofício da “Rede Criança de Combate à Violência Doméstica” (fls. 42/45) e pela prova produzida nos autos.

Sabe-se que a figura típica do crime de atentado violento ao pudor se resume em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, à prática de atos libidinosos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

diversos da conjunção carnal.

Ao analisar detidamente o conjunto probatório, não há dúvidas que os fatos narrados na inicial ocorreram e foram praticados pelo acusado.

Verifica-se que a negativa de autoria, contudo, restou isolada dos elementos de convicção carreados aos autos.

A vítima Andressa afirmou que costumava deitar-se na cama dos pais, juntamente com seu irmão, para conversarem à noite; seu pai nunca tentou estuprá-la, apenas pedia que mexesse em seu pênis. O pai fez isso algumas vezes, até que no dia dos fatos, sua mãe entrou no quarto e flagrou a ação.

Ora, é sabido que em casos de crimes contra os costumes, os quais geralmente são praticados às escondidas, a palavra da vítima, se coerente, equilibrada e amparada nos demais elementos carreados aos autos é bastante para condenar o réu, devendo ser aceita, principalmente em casos como dos autos, em que a mão da vítima flagrou o autor em pleno ato de violência sexual.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CÁRCERE PRIVADO, EXTORSÃO E ESTUPRO. REGIME INTEGRAL FECHADO. NÃO APLICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. WRIT. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA. PENAS-BASE. MÍNIMO LEGAL. ACRÉSCIMO DA PENA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

DOSIMETRIA. ERRO DE CÁLCULO QUE FAVORECEU AO PACIENTE. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. A tese relativa à negativa de autoria não deve, igualmente, ser conhecida, pois, a alegação sub examine, com base na afirmação de deficiência das provas carreadas aos autos da ação penal, demanda, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no estreita via do writ. Ademais a "palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios." (STJ, HC 135.972/SP, 5.^a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.) (grifo nosso).

"ESTUPRO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO AFASTADA - PENA - MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. 1. Em crimes contra os costumes, a palavra da vítima é prova especial, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com os demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução. 2.(...) 3. Recurso desprovido." (Apelação Criminal nº 1.0054.07.027327-8/001; Relator Desembargador Antônio Armando dos Anjos; Julgado em 08/07/2008 e Publicado em 13/08/2008).

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA A, E ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - A palavra da



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios (Precedentes).(...)"(HC 135972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009).

Denota-se, portanto, que os relatos da vítima estão em harmonia com o depoimento da mãe, que no dia dos fatos, flagrou o apelante molestando a própria filha do casal, tendo relatado que, ao ser surpreendido, ele se levantou da cama tentando se justificar, ao mesmo tempo que tentava cobrir a genitália exposta e limpar as mãos na roupa, pois havia ejaculado; a menor também tentava levantar a calça do pijama que estava abaixada, e suja em razão da satisfação da lascívia do pai. Posteriormente, a filha, chorando, relatou que seguidamente vinha sendo molestada sexualmente pelo pai, que a constrangia a masturbá-lo e prometia estuprá-la quando fosse mais velha.

Todo esse contexto probatório, de forma inequívoca, demonstra a veracidade dos fatos narrados pela vítima.

Irrelevante para o processo o fato de não constar exame pericial nas roupas usadas no dia dos fatos, onde haveria vestígios de sêmem do réu, pois não afasta a certeza quanto à autoria do delito em questão, eis que a materialidade do crime de atentado violento ao pudor prescinde do resultado do exame de corpo de delito, porque nem sempre deixa vestígios ou sinais detectáveis por perícia, o que, como cediço na jurisprudência, é



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

comum aos delitos dessa espécie.

Nesse sentido:

TJMS: PENAL - HABEAS CORPUS - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE - LAUDO PERICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA DA PENA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A palavra da vítima, analisada juntamente com as demais circunstâncias que envolvem o crime, é plenamente capaz de servir como meio idôneo de prova e sustentar o decreto condenatório. O exame de corpo de delito nem sempre consegue comprovar a ocorrência do crime, porquanto tal, ao contrário da conjunção carnal, muitas vezes não deixa vestígios, então, nesse caso, o magistrado pode valer-se de outros indícios e evidências, tais como: as palavras das vítimas e testemunhas. Havendo erro material este deve ser corrigido de ofício. (...) (HC nº 2005.013474-6, Rel. Des. João Batista da Costa Marques, em 08/05/2006). – grifei e destaquei.

TJMS: APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – INEXIGÊNCIA DE LAUDO QUANDO O ATO LIBIDINOSO NÃO DEIXAR VESTÍGIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CARÁTER HEDIONDO MESMO EM SUA FORMA SIMPLES – RECURSO IMPROVIDO. O exame de corpo de delito é dispensável para apuração do crime de atentado violento ao pudor, pois este delito não está entre aqueles que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

exigem, necessariamente, o exame pericial, mormente quando a prática de atos libidinosos não deixam vestígios. Os delitos de violento ao pudor e estupro, ainda que cometidos em sua forma simples e mesmo com violência presumida, são considerados crimes hediondos. (AC N. 2008.015895-8, Rel. Desª Marilza Lúcia Fortes, 1ª Turma Criminal, em 07.10.2008)

TJGO: APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ATIPICIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO PERICIAL. DESNECESSIDADE. A conduta delituosa do atentado violento ao pudor caracteriza-se pelo constrangimento produzido por meio de força física ou moral para vencer dissenso da vítima a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, podendo ocorrer sem a realização de nenhum rastro ou vestígio, sendo desnecessária a comprovação pericial para que materializado. (...). (TJGO; ACr 35972-3/213; Aparecida de Goiânia; Rel. Des. Geraldo Leandro Santana Crispim; DJGO 26/11/2009; Pág. 222) – grifei e destaquei.

Por outro lado, por receio do réu que era violento e costumava agredi-la, a mãe da vítima não levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial de imediato, apenas no dia seguinte, razão pela qual não foram apreendidas roupas ou outros objetos que pudessem conter vestígios do ocorrido.

Contudo, o art. 167, do Código de Processo Penal abranda a exigência de prova pericial ao determinar que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

suprir-lhe a falta: *“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”*

Aliás, há muito tempo a jurisprudência e a doutrina reconhecem a dificuldade na produção de prova nos crimes contra a liberdade sexual, valorizando, com isso, a palavra da vítima. Assim, quando em perfeita harmonia com outros elementos de certeza dos autos, a versão apresentada pela ofendida reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria por ela apontada.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: *“(…) Diz o art. 564, III, b que ocorrerá nulidade se não for realizado o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167, isto é, quando não for possível fazer o exame, direto ou indireto, aceita-se a prova de existência do crime por intermédio de testemunhas. Por isso, pode não estar presente o exame de corpo de delito, sem que isso signifique nulidade absoluta, uma vez que a materialidade é provada por outras fontes. (...)”* (Código de Processo Penal Comentado, 9. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 369).

Assim, resta pacificado que o exame de corpo de delito é prescindível à constatação e comprovação do crime de atentado violento ao pudor, mesmo porque em crimes desta espécie, a palavra da vítima é de suma importância ainda mais quando corroborado pelas demais provas colhidas nos autos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Infundada, igualmente, a tese defensiva quanto a possível Síndrome da Alienação Parental.

Ora, é sabido que a alienação parental pode ser deduzida *em qualquer momento processual* e em relação a qualquer das partes ou representantes legais do menor.

Entendemos que há um limite, todavia, consistente na proibição da alegação em grau recursal porque representaria a supressão de um grau de jurisdição. Isso porque referida síndrome se prova através de perícia, com estudos sociais e psicológicos.

Havendo indício da prática de Alienação Parental, o juiz determinará a realização de perícia psicológica na criança ou adolescente, ouvido o Ministério Público.

Face ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz facultar prazo para que o suposto alienador se manifeste acerca da alegação de alienação parental, realizada incidentalmente nos autos já em trâmite

Ora, o apelante em nenhum momento requereu instauração de incidente para apuração da síndrome. Por outro lado, não se constata anormal influência da genitora sobre a menina, a qual já estaria certamente dissipada em razão do tempo decorrido entre a data dos fatos e o seu depoimento em juízo, e provocaria arrependimento ou contradição nas versões da vítima, o que não ocorreu.

Por fim, não cabe desmerecer a palavra da vítima, somente por se tratar de criança, já que narrou os fatos de



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

forma clara e coesa em todas as oportunidades.

A propósito:

"A criança não é necessariamente mentirosa e sugestionável, indo ao ponto da mórbida ou fútil criação de um acontecimento. A sua palavra merece credibilidade, máxime encontrando confirmação nos autos" (TJSP, Apelação Criminal, relator Desembargador Octávio Stucchi; RT 396/102).

"Eliminar, aprioristicamente, o testemunho infantil é entregar a criança, inerme, à sanha dos sátiros. Essencialmente, todas as críticas podem ser feitas ao testemunho como instrumento do processo. É o meio de prova mais passível de infidelidades. Entretanto, o sistema judiciário não prescinde dele" (TJSP, relator Desembargador Acácio Rebouças; RT 420/89).

Assim, no caso presente, a materialidade e a autoria do crime, por parte do apelante, estão devidamente provadas, impondo-se mesmo a condenação do acusado.

A propósito:

"(...) Não se fala em absolvição quando o conjunto probatório existente nos autos for indubitavelmente suficiente para formação do juízo de certeza necessário ao embasamento de decreto condenatório pela prática de crime de atentado violento ao pudor (...)" (TJMG, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Tibagy Salles, Apelação Criminal n. 1.0024.02.627.871-3/001, julgada em 3.2.2004, voto unânime).

Portanto, não há na realidade, que se falar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

em fragilidade probatória.

Com efeito:

"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontestável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12.03.98 - RJTACRIM 38/266).

Com a superveniência da Lei nº 12.015, em vigor desde o dia 10.08.2009, que introduziu alterações nos dispositivos do Código Penal, no Capítulo I, mantida a mesma denominação (Crimes Contra a Liberdade Sexual), revogou expressamente, dentre outros, os artigos 214 e 224, do Código Penal (artigo 7º), o delito em comento se amolda à figura típica do artigo 217-A. *Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.* Ocorre que a pena cominada é superior àquela dantes vigente e, diante da obrigação do Estado em aplicar a lei penal mais favorável ao apelante, mantém-se a capitulação tal como posta na r. *decisum*, mesmo diante da nova adequação típica.

Doravante, a conjunção carnal e o ato libidinoso, se decorrentes de constrangimento exercido mediante violência ou grave ameaça, tipificam o crime único do artigo 213, sob a rubrica de *estupro*.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Mais ainda: se tais condutas – conjunção carnal ou ato libidinoso - ocorrerem com menor de 14 anos, independentemente de violência ou grave ameaça, o crime será o do artigo 217-A, do Código Penal (*estupro de vulnerável*), cujo Capítulo respectivo (II) trata dos "Crimes Sexuais Contra Vulnerável".

Passo a analisar a pena imposta, a qual merece reparo.

Diante das circunstâncias judiciais tidas favoráveis pelo Juízo *a quo*, mantenho a pena-base anunciada na respeitável sentença ora hostilizada, o que corresponde a 06 (seis anos) de reclusão.

Na segunda fase, aumentou a pena em 1/2 (metade), pela incidência do artigo 226, inciso I do Código Penal, perfazendo 09 (nove) anos de reclusão.

Observo, neste ponto, erro material na r. sentença, sendo certo que o referido aumento se deu em razão da incidência da causa de aumento do inciso II do artigo 226 do Código Penal, qual seja, por ser o réu ascendente da vítima, e não como constou (inciso I).

Na terceira e última fase, consigno que assiste razão tanto à Defesa quanto à Douta Procuradoria de Justiça no que tange ao afastamento da causa de aumento prevista no artigo 9º, da Lei nº 8.072/90.

O mencionado artigo dispõe que: “As penas fixadas no Art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, §



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput, e sua combinação com o Art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o Art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 (trinta) anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no Art. 224 também do Código Penal”.

Ocorre que com o advento da Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009, o artigo 224, do Código Penal foi expressamente revogado, conforme dispõe o artigo 7º, da Lei nº 12.015/09. Portanto, entendo que a mencionada causa de aumento foi tacitamente revogada, uma vez que ocorreu a *novatio legis in mellius*, que tem o condão de retroagir aos delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/09, motivo pelo qual afasto tal causa de aumento de pena.

Relativamente ao reconhecimento da continuidade delitiva, conforme acima exposto, a imprecisão pontual dos dias em que se repetiram os atos de constrangimento sexual da vítima, não lhe retira a punibilidade, por se tratar de “requisitos meramente acidentais”.

E estando devidamente comprovado nos autos que os atos de libidinagem se repetiram por mais de uma ocasião, era mesmo de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, aumentando-lhe a pena na proporção mínima de 1/6.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

— ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR — PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO — REJEITADA — PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO — AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS — DISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR EXAME PERICIAL — PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS — DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAÇÃO PENAL — IMPOSSIBILIDADE — CONDUTA DO AGENTE QUE VISAVA AO PRAZER SEXUAL — CONTINUIDADE DELITIVA — IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR QUANTAS VEZES OCORREU O DELITO — DOSAGEM EM GRAU MÍNIMO — REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO — CRIME HEDIONDO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. *Nas hipóteses de crimes sexuais, que a representação da ofendida ou de seu representante legal prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada. O crime de atentado violento ao pudor nem sempre deixa vestígios, razão pela qual o exame pericial pode ser suprido pela prova testemunhal. Em delitos contra os costumes, em que a palavra da vítima inspira segurança e está em harmonia com as demais provas dos autos, inviabiliza-se o pedido de absolvição. Demonstrado que o agente praticou com a vítima atos libidinosos visando à satisfação de sua lascívia, não se tem como operar a desclassificação do crime contra os costumes, para simples contração penal. **Havendo dúvida em relação ao número de***



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

vezes da ocorrência do delito, o aumento pela continuidade delitiva é considerada no grau mínimo, isto é, 1/6 (um sexto). O crime de atentado violento ao pudor tem natureza hedionda, não sendo passível de um regime inicial de cumprimento de pena que não seja o fechado. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2009.012650-7/0000-00 - Nova Andradina - Des. João Carlos Brandes Garcia - TJ/MS).

Ainda:

“ESTUPRO E ATENTADO. MESMA VÍTIMA E CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES. CONTINUIDADE. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E TENTATIVA DE ESTUPRO. INFRAÇÕES COMETIDAS, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 12.015/09, EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, GUARDANDO IDENTIDADE. ATOS POSTERIORES HAVIDOS COMO CONTINUIDADE DO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Segundo o art. 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 2. Após as inovações trazidas pela Lei nº 12.015/09, os arts. 213 e 214 do Código Penal hoje estão condensados no mesmo dispositivo legal, constituindo, dessarte, crimes da mesma espécie, o que viabiliza a aplicação da regra do art. 71 da Lei Penal. 3. No caso presente, o intervalo entre os acontecimentos é de aproximadamente um mês. As condições de lugar (residência do acusado) e maneira de execução (aproveitava-se do fato de a vítima estar dormindo em casa) são absolutamente semelhantes, o que conduz ao reconhecimento do crime continuado. 4. Tomando por base o número de infrações cometidas – 2 (duas) – deve incidir a majoração no patamar de 1/6 (um sexto). 5. A pretensão absolutória esbarra na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, providência de todo incompatível com a via eleita. 6. Ordem parcialmente concedida para, reconhecendo o crime continuado entre as infrações cometidas pelo ora paciente, reduzir a pena sobre ele recaída, de 10 (dez) anos de reclusão para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão”. (HC 114.054/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, STJ, julgado em 05/04/2010, DJe 19/04/2010).

Portanto, partindo da pena de 09 (nove) anos de reclusão, aumento de 1/6, totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva.

3 – Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso interposto por Roberto de Souza, apenas para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

reconhecer a continuidade delitiva e reduzir a pena para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, afastado o concurso material do artigo 69 do Código Penal, por infração do artigo 214 c.c. artigo 225, § 1º, inciso II e artigo 226, inciso II, (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal mantida no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio **Rossi**
Relator